

1521659-25.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... lícito, não tem o condão de descaracterizar o tráfico, pois é cediço que uma conduta não exclui a outra e é comum o tráfico por dependentes, até mesmo para ajudar a financiar o vício.

Assim é que decido.

Passo, portanto, à fixação da pena.

I) Art. 33, da Lei nº 11.343/06:

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco (05) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1521659-25.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521659-25.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2259381/2019 - 34º D.P. MORUMBI, 7249929 - 34º D.P. MORUMBI, 3410/19/338 - 34º

D.P. MORUMBI, 2259381 - 34º D.P. MORUMBI, 3410/19/338 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO BARBOSA DE JESUS

M.M.^a Juíza de Direito: Dr.^a Tatiana Franklin Regueira

Vistos.

Francisco Barbosa de Jesus, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 33, § 1.º, inciso II, ambos da Lei n.º 11.343/06: I) porque supostamente no dia 05 de setembro de 2019, por volta de 11hs20min, na rua Alessandro Bibiena, altura do numeral 160, Vila Sônia, nesta Capital, trazia consigo, com o intuito de entrega para consumo de terceiros, quarenta invólucros de "maconha", com peso líquido de 89,2 gramas, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo

com determinação legal; II) também porque, supostamente nas mesmas circunstâncias de tempo e local, semeou e cultivou uma muda de Cannabis Sativa, planta esta que constitui em matéria-prima para a preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida às fls. 60/61, o acusado foi citado à fl. 289, apresentou defesa às fls. 102/138 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 162/163), momento em que ouvidas quatro testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 292/295). Em seguida, procedeu-se à execução de diligências complementares solicitadas pela d. Defesa. Após, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação (fls. 322, 346 e 466). Já a d. Defesa, requereu a absolvição, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória e nulidade do ingresso na residência. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta delitiva, aplicação máxima da minorante prevista no § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, por fim, fixação do regime inicial aberto (fls. 472/523).

É o relatório do essencial.
Fundamento e Decido.

Preliminarmente, não há que falar-se em desrespeito à inviolabilidade do domicílio, eis que os autos se ressentem de elementos objetivos aptos a embasar a suposta violação de referido instituto.

Note-se que a prova é segura no sentido de que o réu foi perseguido após jogar uma sacola ao solo até sua residência, onde localizada a planta de "maconha", tratando-se, dessa forma, de crime permanente, ou seja, nessa hipótese, a consumação do delito se protraí no tempo, de forma que o agente ficará em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência.

Assim, a redação do art. 5º, XI, da CF, que trata da inviolabilidade do lar, exclui as situações de flagrante delito daquelas em não se poderá adentrar em domicílio do indivíduo sem o seu consentimento, sendo desnecessária a autorização judicial para realização da busca em residência em tais circunstâncias, pois "tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial." (STJ HC nº 267968/RJ Rel.: Min. Laurita Vaz. j. 15/08/2013).

Ultrapassada tal questão, no mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

Assim porque ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado por trazer consigo substância entorpecentes para fins de tráfico, todavia, de rigor a desclassificação da conduta delitiva prevista no § 1º, inciso I, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o § 1º, do art. 28, da mesma lei em relação à planta de "maconha" localizada em sua residência.

A materialidade restou consubstanciada através do boletim de ocorrência de fls. 03/05, auto de exibição e apreensão de fl. 08, laudo de constatação de fl. 10/12, laudo do exame químico-toxicológico de fls. 177/179, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria também é indubitável.

Coram judice o réu disse que estava saindo de casa para o serviço às 9hs45min, os policiais estavam na sua porta e, ao passar foi abordado. Os policiais pediram para entrar na residência. Disse que não, mas eles disseram que entrariam de qualquer jeito. Abriu a porta para os policiais, que encontraram um pé de "maconha". Tinha consigo apenas um saco com lixo. Não conhecia os policiais. Não teve outro processo. Os policiais mostraram a sacola plástica com drogas apenas na Delegacia. Ficou bastante tempo na viatura. Crê que a sacola estava dentro da viatura. Uma hora antes os policiais abordaram um pessoal lá em cima na favela. Trabalha no açougue. Tem certeza do horário porque é o que sempre sai para o serviço. Fazia uso de "maconha". Acredita que tenha sido abordado porque os policiais viram que estava com uma "ponta". Estava com a mochila e a sacola de lixo branca. Na mochila tinha apenas a marmita e o uniforme; pediu para levarem a marmita e o uniforme para mostrar para o Delegado e eles não deixaram. Eles avisaram sua vizinha que ele iria preso. Os policiais ficaram meia hora dentro de sua casa. Subiram para a rua principal até a viatura. Havia um terceiro policial que ficou na viatura. Ficou rodando com os policiais e depois parou em uma rua deserta; eles lhe disseram que era apontar o pessoal da biqueira se não iria preso no lugar deles; haviam várias viaturas. Os policiais pediram para duas viaturas olharem na viela para ver se encontravam alguma coisa. Eles fizeram chamada de vídeo com outra pessoa. Negou que a droga fosse sua, apenas tinha uma "ponta" e o pé de "maconha"; nem chegou a fazer uso da maconha que plantou. Morava com o irmão e o primo. Foi forjado pelos policiais; é inocente.

Tal negativa, contudo, restou desmentida pelos demais elementos dos autos.

Com efeito, o policial militar Heber Júnior Pantaleão afirmou se recordar vagamente do réu. Disse que foi uma ocorrência de tráfico de drogas, em que o indivíduo evadiu-se para o interior da comunidade e deixou um saco preto para trás. Solicitou apoio, abordaram e fizeram a vistoria na viela; a residência dele foi vistoriada; ele estava com uma mochila. Encontraram a droga no saco preto e um vaso de planta de maconha na residência. Havia porções individualizadas de "maconha", mais de vinte. O réu avistou a viatura, largou a sacola e saiu correndo. A casa dele para a qual ele correu estava a cinquenta metros; lá encontraram apenas a planta. Era uma sacola preta. Não sabe precisar a distância que estava do acusado. Ele foi abordado do lado de fora da residência e autorizou a entrada. Desceram da viatura, pegou a sacola e foram ao encalço dele. Tem o hábito de expor para a pessoa que ela tem o direito de não consentir com a entrada na residência. Após a saída da residência foi consultado o RG, CPF e os antecedentes do acusado, via Copom. A viatura não tem tablet; não sabe se tem GPS. Havia uma outra viatura na via quando avistaram o acusado. O relatório foi feito à mão. Sempre pedem apoio via rádio. Conversas informais são feitas por telefone; conversas de serviço são via rádio. Iniciou o plantão às 5hs30min; o patrulhamento fica documentado. Não se recorda o que foi feito com a mochila dele nem o que havia dentro. A ocorrência se iniciou às 11hs20min; saíram do local dos fatos e foram para a Delegacia; na Delegacia um policial vai dar ciência ao Delegado e o outro fica qualificando o indivíduo.

No mesmo sentido o policial militar Guilherme Dutra Garcia Lopes afirmou que estavam em patrulhamento pelas imediações do Jardim Jaqueline quando o acusado, ao notar a presença da viatura, se evadiu para o interior da comunidade arremessando uma sacola plástica na cor preta. De imediato desembarcou e foi ao encalço dele; o outro policial pediu apoio na rede, pegou a sacola e foi ao seu encontro. O acusado adentrou a uma viela e foi detido entrando em uma residência, que informou ser sua; quando foi detido ele havia acabado de abrir a porta. Na busca pessoal foram encontrados dois aparelhos celulares no bolso da calça jeans. Na residência, em uma espécie de varanda no andar superior, foi encontrado um pé de "maconha" de aproximadamente cinquenta centímetros. Após, saíram da viela e na sacola preta constatarem as porções de "maconha"; por volta de quarenta porções; abriram a sacola na frente do guarda-presos, na presença do acusado; era sacola preta, mais ou menos do tamanho de uma de mercado. Ele nada lhe disse. A diligência foi por volta

do horário do almoço, de 11hs30min a 13hs30min. Não se recorda de mochila. Nada mais de ilícito encontraram na casa; haviam outras camas. Não o conhecia antes dos fatos. A consulta dos dados dele foi feita na viatura; foi feita pelo nome porque estava apenas com a carteira de trabalho com RG da cidade natal dele, no nordeste; fez a pesquisa pelo Copom; pelo tablet é possível apenas fazer pesquisa quando o RG é do estado de São Paulo. O depoente e o parceiro saíram da viatura. Abordou o acusado e o parceiro já veio atrás. O acusado já havia aberto a porta e disse que iria vistoriar a residência; em momento algum negou o ingresso à residência, ele autorizou. No momento da entrada na residência a sacola não havia sido aberta ainda. Vistoriaram todos os cômodos da casa. Saíram da residência, foram até a viatura; mais equipes estavam no apoio; quando sentiram insegurança fizeram a pesquisa; neste momento já havia aberto a sacola. Viu o acusado arremessando a sacola, passou por ela e foi ao encalço dele. Nada disse para a vizinha do acusado. Havia mais policiais. Os dois celulares foram entregues. O depoente quem escreveu o BOPM. Não se recorda do acusado portando mochila. Ele disse que trabalhava em açougue; portava carteira de trabalho. Todas as viaturas são monitoradas; não tem como desligar o GPS. Entrou no serviço às 5hs30min. É feito um relatório do serviço. Durante o acompanhamento havia bastante gente nas vielas. A comunicação é feita via rádio; nem todas as equipes possuem o rádio portátil, aí fazem comunicação via celular. Não fez chamada de vídeo na data dos fatos.

Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96).

Os policiais sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Saliente-se, ainda, que pequenas divergências referentes a dados secundários não são suficientes para infirmar os depoimentos, vez que coerentes e harmônicos em relação à materialidade e autorias delitivas. Assim, desacreditar referidos testemunhos em razão das pequenas e irrelevantes divergências apontadas seria acatar verdadeiro conluio criminoso entre policiais que estariam às ruas caçando pessoas inocentes para imputar-lhes crimes, o que não parece crível.

Observa-se, ademais, que referidos testemunhos, encontram-se em consonância com o B.O.P.M. (fls. 312/313) e documento de fls. 410 (consulta via COPOM), bem como não foram elididos pelos testemunhos dos policiais civis.

O Delegado de Polícia Fábio Vitols Brandão afirmou que a ocorrência, que é corriqueira, foi apresentada por volta de meio dia; ao final do dia, com a chegada dos laudos, fez a oitiva do acusado. Não se recorda da apresentação dos aparelhos celulares; o que foi apresentado foi apreendido; não viu mochila; viu um saco plástico preto com invólucros de "maconha". O acusado não assumiu o tráfico e nem a propriedade da sacola; ele disse que era apenas usuário de maconha e que tinha um vaso de maconha. Ele disse que foi pego pela polícia militar quando estava indo trabalhar, portando um cigarro de maconha; ele disse que estava com sacola de lixo. Não foram apresentadas a sacola de lixo e nem a mochila. Teve que tomar uma decisão; a ocorrência foi apresentada por policiais militares, que possuem presunção de legitimidade nas declarações; tentaram entrar em contato com familiares e não lograram encontrar testemunhas em relação à versão do acusado. Ele não aparentava ter sido lesionado. A sacola parecia ser um pedaço de saco preto; era pequena.

Por fim, o policial civil Rodrigo Gois afirmou que diariamente são apresentados objetos que os policiais militares creem fazer parte da ocorrência; na Delegacia costumam separar o que realmente faz parte e o que não faz. Compareceram familiares do acusado e a eles restituiu alguns objetos. A mochila não foi apresentada. O acusado negou a todo momento a traficância. O depoente tem por costuma fotografar o que é apresentado – apresentou imagens do que havia na sacola e da planta. A sacola era fechada, como se fosse um saco de lixo ou uma sacolinha.

Como se vê, não há dúvida que o réu foi surpreendido portando porções de "maconha" para fins de tráfico e semeando uma planta de "maconha" em sua residência.

Todavia, considerando que na residência do réu, além de referida planta de cerca de cinquenta centímetros, nada mais foi localizado que indicasse que ela se destinaria à mercância ilícita, de rigor a desclassificação de tal conduta prevista no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06 para o previsto no § 1º, do art. 28, da mesma lei.

Observo, por derradeiro, que o fato de o acusado ser usuário de substância entorpecente e possuir trabalho lícito, não tem o condão de descaracterizar o tráfico, pois é cediço que uma conduta não exclui a outra e é comum o tráfico por dependentes, até mesmo para ajudar a financiar o vício.

Assim é que decido.

Passo, portanto, à fixação da pena.

I) Art. 33, da Lei nº 11.343/06:

Nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da reprimenda, não há circunstâncias a considerar.

Observo, outrossim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu é primário, demonstrou ter trabalho lícito e não foi surpreendido com grande quantidade de substância entorpecente, razão pela qual não é possível presumir que o réu integre organização criminosa ou se dedique, de forma habitual, à referida atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em dois terços (2/3), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixadas em seu valor unitário mínimo.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Considerando a pena ora aplicada, a primariedade do réu e quantidade de substância entorpecente apreendida, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, suficiente para a repressão de sua conduta (art. 33, do C.P.).

II) Art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06:

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, c.c. artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, considerando o tamanho e peso da planta encontrada na residência, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco (05) meses.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Francisco Barbosa de Jesus, qualificado nos autos, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixadas em seu

valor unitário mínimo, por incursão no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de cinco (05) meses, por incursão no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao presente processo em liberdade, razão pela qual poderá apelar da mesma forma.

Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, estando presentes os demais requisitos legais e por ser suficiente para a reprovação e prevenção da conduta, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal imposta, em local a ser fixado pelo juízo da execução, bem como pela pena de multa, qual seja, dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Importante anotar que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e por multa não prejudica o regular pagamento da pena de multa imposta, originalmente, de forma cumulativa, permanecendo exigível.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento encaminhando-se à V.E.C. Competente.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas.

Isento de custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de março de 2022.

Tatiana Franklin Regueira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA